第 31 卷第 4 期 中南大学学报(社会科学版) Vol.31 No.4
2025 年 7 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCES) Jul. 2025
DOI: 10.11817/j.issn. 1672-3104. 2025. 04. 008

气候变化措施适用国际投资协定安全例外条款：可行性及其限制

邓婷婷，曹江琪

(中南大学法学院，湖南长沙，410083)

摘要：随着气候变化问题的安全化，东道国在国际投资仲裁案中援引国际投资协定(IIAs)的安全例外条款为其气候变化措施进行抗辩的可能性日益显现。近年来，IIAs 的安全例外条款在协定文本和实践适用层面均呈现出例外情形扩张、关联性标准降低的发展趋势，这使得东道国的气候变化措施获得投资保护义务豁免具备了可行性。然而，东道国一旦成功援引安全例外条款，将会引发双重效应：一方面能够有效保障东道国的气候规制权，另一方面则可能进一步模糊安全例外条款的适用门槛和边界，增加该条款在气候变化安全化背景下被滥用的风险。为了在保障东道国气候公共利益的同时维持安全例外条款例外适用和规制平衡的应然状态，各国应当明确将气候变化列为安全例外情形，并通过纳入“最低限制性替代措施”的必要性审查标准、增加条款适用的限制条件以促进条款主客观因素的再平衡。仲裁庭在解释和适用安全例外条款时，也应当合理运用演进解释和细化善意原则的审查标准，限制气候变化措施适用安全例外条款的边界。

关键词：气候变化；国际投资协定；安全例外条款；涉气候变化投资争端；安全化

中图分类号：DF964 **文献标识码：**A **文章编号：**1672-3104(2025)04−0081−17

气候变化是 21 世纪人类面临的最紧迫的问题之一。近年来，各国为履行国际气候减排义务、加快能源转型而采取的气候变化措施引发了多起国际投资仲裁案，化石能源、可再生能源等已成为国际投资仲裁实践中的焦点领域。为了有效避免投资者−国家争端解决(Investor−State Dispute Settlement，以下简称 ISDS)机制对东道国气候规制权产生的“寒蝉效应”，各国已在国际投资协定(International Investment Agreements，以下简称 IIAs)的条约实践中通过明确禁止征收、非歧视待遇等实体性义务的例外情形以及扩张一般例外条款的适用范围等方式拓展东道国的政策空间。然而，伴随着气候变化给国家生态环境、社会稳定、地缘政治竞争等带来的多重影响的加剧，其“安全化”趋向越来越明显，不仅被纳入联合国安理会(以下简称安理会)的讨论范畴，也被美国、英国等纳入国家安全战略之中。近年来，随着经济危机、跨国犯罪、恐怖主义等影响国内安全的问题不断出现，东道国愈加关注安全例外条款保障国家监管权的制度功能，在投资仲裁争端中援引安全例外进行抗辩的频率显著上升。可以预见的是，在未来的涉气候变化投资争端中，IIAs 安全例外条款被东道国用以正当化其气候变化措施、推进其气候安全战略的可能性也将随之增加。

尽管目前尚未有仲裁庭专门针对东道国气候变化措施能否适用安全例外条款作出解释，但在气候变化安全化的背景下，前瞻性地思考东道国气候变化措施适用安全例外条款的可行性，并提出防止安全例外条款被滥用的有效路径，能够为明确安全例外条款在非传统安全时代的适用边界、协调全球气候治理和投资治理提供新思路。

收稿日期：2024−12−25；**修回日期：**2025−03−09
基金项目：国家社会科学基金项目“气候变化全球治理下国际投资协定的改革及中国方案研究”(24BFX148)
作者简介：邓婷婷，女，湖南长沙人，法学博士，中南大学法学院副教授，主要研究方向：国际投资法、WTO 法、国际争端解决，联系邮箱：lwkiko@163.com；曹江琪，女，河南新乡人，中南大学法学院硕士研究生，主要研究方向：国际投资法

中国知网 https://www.cnki.net

一、应对气候变化：IIAs 安全例外条款适用的新情境

虽然气候变化本质上属于生态环境问题，但其对社会、经济、能源等多个领域产生的系统影响给国家安全带来了多重威胁。为了加强气候治理，部分国际组织和国家逐渐将气候变化升级为安全层面的问题加以探讨和应对。随着气候变化的安全化，东道国的气候变化措施能否被纳入安全例外条款的适用范围，已成为非传统安全时代解释适用安全例外条款需要回应的新问题。

(一) 气候变化问题的安全化

国家安全是对国家的生存和发展没有或很少受到重大威胁的状态的一种界定[1]，最初指保护一国领土免受外部军事威胁和攻击，具有强烈的军事及政治色彩[2]。冷战结束之后，鉴于国家安全威胁来源在非军事领域的出现以及国家安全概念仅限于军事领域导致的资源分配不公等问题[3]，国家安全概念逐渐抽象化，并突破物理空间和领域范围的限制扩展到非军事领域[4]。在此过程中，越来越多的议题从非安全议题升级为相关群体认可的、对其生存产生威胁、需要优先采取紧急措施加以应对的安全议题[5]，成为非传统安全的组成部分。

在国家安全概念扩张之初，学者们便关注到环境问题给国家生存和发展带来的威胁，但主要侧重于考量资源稀缺可能导致的国内或国际冲突，并未将气候变化作为环境安全的重点[5]。进入 21 世纪后，随着气候变化及其影响的加剧以及国际社会对气候变化科学认知的深化，气候变化和安全之间的联系受到广泛关注[6]。在国内层面，越来越多的国家开始审查气候变化对主权和领土完整的威胁，并将其纳入国家安全范畴。英国 2008 年出台的《英国国家安全战略：相互依存世界中的安全》将气候变化描述为国际稳定和安全以及国家安全潜在的最大挑战，认为其不仅会直接引发极端天气等自然灾害，同时会对水、能源和粮食安全造成威胁①；2010 年美国《国家安全战略》指出气候变化导致的土地退化、难民流动等问题以及由此引发的冲突已构成紧迫且日益严重的威胁②。在国际层面，联合国也开始探究气候变化对国际安全和稳定甚至对整个人类安全的威胁。安理会 2007 年召开的以“能源、气候与安全”为主题的公开辩论首次针对气候变化与安全的关联进行了讨论，并在之后围绕安理会在应对气候安全问题中的正当性等主题多次召集公开辩论，在推动成员方凝聚气候安全共识以及气候变化的安全化方面发挥了重要作用。2008 年，联合国环境规划署对萨赫勒地区进行调查后提出气候变化是该地区资源短缺、移民等问题的驱动因素之一，同时会引发冲突，危及该区域甚至国际社会的安全③。

由于气候变化的长时段性、非均衡性、复杂性等特征，以及各国在气候变化带来的具体威胁、治理框架等方面的认知差异和立场分歧，各国对气候变化安全化的态度和推进国内气候变化的安全化进程不尽相同[7]。然而，不可否认的是，国际社会已普遍认识到气候变化与安全之间的联系日益紧密，并致力于探索如何应对气候变化给生态、社会、经济等系统造成的安全威胁。气候变化的安全化已推动气候安全成为非传统安全领域的重要议题。

(二) 气候变化措施在 IIAs 下的安全例外抗辩

在 IIAs 以投资保护和投资自由化为主要目标的发展阶段，安全例外条款并未受到各国的重视。尤其是发展中国家，往往为了吸引外国直接投资的流入而在监管权方面作出妥协，较少纳入安全例外或者其他例外条款[8]。即使在 IIAs 中规定了安全例外条款，相关国家也秉持非必要不使用的克制态度，在投资争端中极少援引[9]。随着 21 世纪初经济危机以及多元性安全因素介入国际投资法治，国家强化安全监管的需求日益凸显[10]。各国逐渐在条约实践中加强对国家利益等非投资性利益的关切，推动 IIAs 向追求多元化价值平衡转型。安全例外条款也由于其平衡投资者保护和国家监管权的功能得到重视。在东道国维护国家安全利益的监管措施引发投资争端的情况下，各国开始援引安全例外条款作为

中国知网 https://www.cnki.net

其扩张安全政策空间的合法依据。

现有的涉及安全例外条款的投资仲裁案主要包括阿根廷政府为应对经济危机采取的监管措施所引发的阿根廷经济危机系列案；印度政府基于 S 波段频谱的不合理分配会危及电信安全而取消其与 CC/Devas 公司的合同所产生的印度电信双案；多米尼加政府为应对圣多明各严重的健康和环境危机采取的措施所引发的案件(Michael Anthony Lee-Chin v. Dominican Republic，以下简称 Lee-Chin 案)以及哥伦比亚政府为打击有组织犯罪而扣押投资者投资的房地产项目引发的案件(Seda v. Colombia，以下简称 Seda 案)④。这些案件的仲裁裁决在推动安全例外条款适用要件发展的同时，也打开了经济安全、电信安全、环境安全、打击有组织犯罪等非传统安全适用安全例外条款的窗口。在 Discovery Global v. Slovakia 案中，斯洛伐克也援引了安全例外条款作为其抗辩依据之一，并将保护环境、确保水和清洁空气的获取、尊重当地社区维护自身利益的权利及防止内乱定性为基本安全利益⑤。Discovery Global 公司主张基本安全利益“不能超出其自然和一般含义”，但承认安全概念可以包括经济安全和能源安全⑥。事实上，在阿根廷经济危机系列案中，有仲裁员发表异议时就已提及，基本安全利益的概念范围不限于涉及国家存在的利益，还关涉非传统安全时代的生态、能源等安全利益⑦。由此可见，在仲裁实践中，仲裁庭、东道国和投资者对基本安全利益可以涵括多元性非传统安全的认识正在不断提升。

气候变化的影响是复杂的，会对陆地、海洋等生态系统造成破坏，影响全球能源供需等，从而作用于环境安全、能源安全等其他安全领域，形成“复合安全”(complex security)挑战[11]。随着气候变化安全威胁来源的增加以及程度的加深，相关国家会将应对气候变化定位为安全战略中的优先事项，继续推动气候变化安全化进程。在此背景下，东道国实施限制或禁止外国高碳投资、改变监管框架等广泛的气候变化政策，存在减损投资者合理期待，引发国际投资争端的潜在风险。尽管目前涉气候变化的 ISDS 案件中尚未涉及安全例外条款的适用，但东道国未来援引安全例外条款为其气候措施进行抗辩的可能性伴随着气候变化安全化的推进而极大增加。

此外，与一般例外条款以及禁止征收等特定条款的例外不同，大多数安全例外条款不仅可以适用于整个 IIA，更为重要的是，通过越来越多地在该条款中纳入“缔约方认为”等自裁性措辞赋予缔约方较为宽泛的规制空间，使得其已具有抗辩权和自裁权的双重属性[4]。可以看出，安全例外条款已成为东道国应对气候变化、维护气候安全的“新安全阀”。

二、气候变化措施适用 IIAs 安全例外条款可行性的文本分析

随着国际安全形势的复杂化和保障国家安全利益需求的增加，IIAs 中纳入安全例外条款呈上升趋势，其条款内容和适用范围也在不断发展变化。因此，东道国以安全例外为由正当化其气候变化措施是否具有可行性，应当首先基于安全例外条款的文本规定加以分析。

(一) IIAs 安全例外条款的文本范式

基于规制需求、政策目标等因素的不同，各国在 IIAs 条约实践中探索并达成了复杂多样、表述各异的安全例外条款。但究其规范结构，该条款主要存在列举式和概念式两种范式。

列举式安全例外条款可以追溯至作为现代投资协定前身的《友好通商航海条约》中的例外条款。例如 1946 年签订的《中美友好通商航海条约》第 26.1 条规定，该条约的任何条款不得解释为阻止缔约方为履行维持国际和平及安全之义务，于国家紧急时期保护本国基本利益(essential interests)等情形下采取必需措施。此类规定的内在逻辑在于，在军事、战争等紧急状态下优先维护国家基本利益，是缔约方背离条约义务、放弃部分经贸利益的例外措施和正当选择[12]。20 世纪 40 年代战后盟国制定的《国际贸易组织宪章》第 99 条、《关税与贸易总协定》(*General Agreement on Tariffs and Trade*，以下

中国知网　https://www.cnki.net

简称 GATT)第 21 条延续了这一设计理念和立场，并采用“基本安全利益”(essential security interests)的表述，同时更为详尽具体地列明了协定所允许的安全例外情形，包括不得要求缔约方提供认为如披露会违背其基本安全利益的任何信息、不得阻止缔约方采取其认为对保护基本安全利益所必要的行动等。作为多边经贸协定中首次明确规定的安全例外条款[13]，GATT 第 21 条不仅在乌拉圭回合谈判达成的 GATT1994 中被保留下来，此后也成了国际经贸协定中具有示范意义的安全例外的“母条款”[14]。鉴于该条款较为广泛的接受度和成熟的规范结构，部分国家在缔结 IIAs 安全例外条款时以此为蓝本或者直接加以援引，规定不得阻止缔约方采取其认为对保护基本安全利益所必要的措施，包括与武器、弹药和战争工具的贸易有关的措施，在战时或国际关系中的其他紧急情况下采取的措施等⑧。

概念式安全例外条款肇始于 20 世纪 50 年代末。各国在谈判双边投资协定(Bilateral Investment Treaty，以下简称 BIT)时认识到，当出现影响其公共政策维护并需要从根本上改变其政策优先事项的紧急情况时，东道国可能无法履行其协定义务[15]。1959 年，德国−巴基斯坦 BIT 议定书第 2 条规定，基于公共安全和秩序、公共健康或道德原因采取的措施不得被视为非歧视待遇条款下的歧视待遇。为进一步增强缔约方采取安全措施的灵活性，美国−塞内加尔 BIT 第 10 条、中国−新加坡 BIT 第 11 条等将安全例外的适用范围拓展至整个协定，并采纳了“基本安全利益”的概念，规定协定不得排除或限制缔约方为保护公共卫生、公共秩序或者自身基本安全利益而采取(必要)措施的权利。与列举式安全例外条款不同，此类条款将安全与公共秩序、卫生、健康等其他同样具有抽象性的公共政策目标并列，仅概括性规定缔约方采取必要措施维持其公共秩序或保护自己的基本安全利益的权利。此后，印度−尼泊尔 BIT 第 12.2 条、以色列−缅甸 BIT 第 7.1 条等安全例外条款在删除“公共秩序”等其他政策目标的同时，仍然保留了安全利益概念的抽象性和模糊性，未对其范围作出进一步规定或解释。

通过比较可以发现，列举式和概念式安全例外条款虽然在表述范式上存在差异，但在关键要素和具体表述方面具有共性，即均要求缔约方采取的安全措施满足维护国家安全利益的目的性和所涉措施与维护国家安全利益之间的关联性两项条件。

(二) 气候变化措施的国家安全利益属性

国家安全利益是 IIAs 安全例外条款中最核心也最具模糊性的表述之一，与各国对国家安全这一概念的动态理解密切相关。在 IIAs 的发展初期，虽然缔约方未对概念式安全例外条款中的“公共安全和秩序”“基本安全利益”等概念作进一步释明，但在当时的国际社会背景下，以国家利益为唯一导向的传统安全观念占据主导地位，国家安全尚未被赋予广泛含义[16]。随着经济全球化水平的提升、科学技术的快速变革等多重因素的相互交织，新型安全风险迭出[17]，非传统安全因素在国家安全观念中的重要性不断提升，国际社会对国家安全的关注更多地从政治军事转向人类和社会发展问题[18]。在此背景下，各国在 IIAs 缔结过程中开始通过丰富条约用语来表明其广义理解国家安全利益的缔约意图[3]，例如选择“公共安全”“国家安全”“国家利益”“国家安全利益”等表述⑨。从文义解释的角度来看，“基本安全利益”包括基本和安全利益两个概念要素，指涉及国家核心职能、比一般公共利益重要层级更高的安全利益⑩，其涵盖范围显然窄于“国家利益”[19]。而“公共安全”“国家安全”等用语通常指一国保护国家及其公民免受广泛的威胁⑪，一定程度上也为非传统安全的纳入预留了更灵活、弹性的解释空间。基于此，在适用概念式安全例外条款时，缔约方不仅被允许采取其认为对保护传统安全利益所必要的措施，还可以就经济、公共健康、环境等非传统安全事项进行例外抗辩[20]。

气候变化对国家安全的影响体现在两个层面。一方面，气候变化会给国家的生态、社会、经济系统等人类和社会发展造成威胁，例如太平洋地区的小岛屿国家瓦努阿图由于遭受海平面上升、极端天气等严重影响，已于 2022 年宣布进入气候紧急状态，声明气候变化是其公民生存、安全和福祉的最大威胁⑫。另一方面，气候变化因引发资源稀缺、移民等问题也会直接或间接危及国家的政治、军事安全。换言之，气候安全虽然本身属于非传统安全领域，但又与国家的传统安全利益相关联。在安全

中国知网 https://www.cnki.net

例外条款中国家安全利益涵盖范围向非传统安全因素拓展的背景下，不论东道国传统安全利益抑或非传统安全利益受到气候变化的严重威胁，在协定文本层面都有被国家安全利益范围所囊括的可能性。

相比之下，列举式安全例外条款中国家安全利益涵盖范围的发展变化则更为具象，主要表现在三个方面：一是部分安全例外条款不再限制“战时或国际关系中的其他紧急情况”中“紧急情况”的国际性，允许缔约方在国内紧急状态下采取必要措施。例如白俄罗斯-印度 BIT 第 33.1 条规定，本协定的任何条款不得解释为阻止缔约方采取其认为保护基本安全利益所必需的任何行动，包括在战时、国内或国际关系中的其他紧急情况下采取的行动。这意味着，无论气候变化导致的资源争夺、移民等问题引发或者加剧一国国内紧急状态还是国际紧张局势，东道国采取的气候变化措施都可能构成国家安全例外情形。二是许多 IIAs 逐渐摆脱 GATT 第 21 条将基本安全利益只限于军事类安全因素的范式而纳入其他非传统安全因素，例如《区域全面经济伙伴关系协定》第 17.13 条规定，本协定的任何条款不得解释为阻止缔约方采取其认为对保护包括通讯、电力和水利基础设施在内的关键公共基础设施所必需的行动。正如联合国政府间气候变化专门委员会在报告中指出的，气候变化引起的海平面上升、冻土融化等现象会破坏一国的关键基础设施，削减本国应对气候变化和自然灾害、维护国家安全的能力⑬。由此，东道国为了避免本国关键基础设施受到威胁而采取的相关气候变化措施，能够直接适用将保护关键公共基础设施明确纳入基本安全利益的例外条款。三是部分安全例外条款增加了“包括”(including)、“包括但不限于”(including but not limited to)等措辞⑭，凸显其列举事项的非穷尽性以及对基本安全利益涵盖范围的开放立场。这更加明确地表明，在气候变化引发极端天气、水资源短缺等其他未被列举但严重威胁东道国安全利益的情形下，东道国仍然有权采取其认为必要的安全措施。

(三) 气候变化措施与维护国家安全利益之间的关联性

关联性条件要求东道国采取的措施与维护基本安全利益之间存在一定程度的因果联系。受列举式安全例外条款范式的影响，部分概念式安全例外条款也将这种联系表述为“必要的”(necessary)。在仲裁实践中，必要性通常被解释为“不可或缺的”“作出实质性或者决定性贡献的”⑮，对东道国采取的措施与基本安全利益的关联性往往适用较为严格的审查标准。为充分保障自身维护国家安全利益的监管自由，一些国家通过纳入“其认为”等自裁性措辞来增强条款适用的主观判断因素，压缩仲裁庭的客观审查范围[10]；另有部分国家采用“旨在”(directed to/intended to/for)等其他连接词⑯，规定只要东道国采取的措施涉及国家安全利益即可，极大降低了相关措施与基本安全利益的联结标准⑰。

与其他国家安全问题相比，应对气候变化的复杂性在于其涉及多领域、多维度的协调和治理。东道国在面临气候危机时，可能会采取减少化石燃料使用、限制化石燃料密集型活动等缓解措施，以及建设防洪基础设施、调整土地利用和管理政策等紧急应对措施⑱。相较而言，东道国采取的紧急应对措施更具有针对性、效果即时性等特征，在保障东道国国内秩序与安全利益方面的不可或缺性或实质性贡献更容易被证明，从而满足必要性条件[21]。而气候变化减缓措施的效果具有长期性和跨国性，加之其效果评估对科学技术的要求较高，导致相关措施对缓解气候变化整体目标、降低气候变化对东道国安全利益威胁的贡献难以衡量，东道国在争端解决实践中很难提供足够的客观证据。但在适用规定“其认为必要的”“适当的”“旨在”等联结条件的安全例外条款时，东道国的自由裁量权被给予较大程度的尊重，东道国只需证明其是善意采取的气候变化减缓措施或者其措施与应对气候危机之间存在合理联系即可⑰。这极大减轻了东道国的举证责任，提高了其气候变化措施满足关联性要件的可能性。

三、气候变化措施适用 IIAs 安全例外条款可行性的实践考察

由于安全例外条款的高度抽象性和标准模糊性，其在争端解决实践中的适用边界尚不清晰[22]。然

中国知网　https://www.cnki.net

而，基于国际经贸协定中安全例外条款的文本范式和表述存在相似性，国际投资仲裁庭和世界贸易组织(World Trade Organization，以下简称 WTO)专家组对安全例外条款的解读逻辑具有共识性。仲裁庭和 WTO 专家组对非传统安全属于基本安全利益的开放态度及对相关措施与维护基本安全利益之间关联性的裁判说理，为考察气候变化措施适用 IIAs 安全例外条款的可行性提供了重要支撑和有益参考。

(一) 安全例外条款的裁判逻辑

从既有争端解决实践来看，国际投资仲裁实践目前只涉及概念式安全例外条款的适用，对于列举式安全例外条款的理解则需要参照 WTO 专家组对 GATT 第 21 条的阐释。为了明确安全例外条款的裁判逻辑，有必要对现有涉及安全例外条款的案件进行梳理归纳(见表 1)。

从表 1 中可以看出，虽然涉及安全例外条款的案件在具体案情、适用条款、裁判说理以及裁决结果等方面不尽相同，但综合国际投资仲裁庭和 WTO 专家组的裁决思路，判定东道国采取的措施能否属于安全例外抗辩事由的关键在于其是否能满足安全例外情形的事项条件和措施的关联性条件。

(二) 气候变化措施符合安全例外条款的安全事项条件

现有的投资仲裁裁决已经认定经济安全、电信安全和打击有组织犯罪等属于基本安全利益范畴，彰显了多元性非传统安全适用安全例外条款的可能性。不同的是，阿根廷经济危机系列案和 Lee−Chin 案涉及东道国面临的现实安全威胁，而印度电信双案和 Seda 案是对东道国预防潜在安全威胁相关利益的定性。这种差异推动仲裁庭对基本安全利益的判定逻辑分为紧急情况下的应对主义以及非紧急情况下的预防主义[23]。缓解和适应是应对气候变化的平行且互补的两种方式，气候变化措施兼具应对性和预防性。因此，需要分别对东道国在不同情形下采取的气候变化措施涉及的基本安全利益进行判断。

1. 安全事项之一：东道国在气候紧急情况下采取的气候变化措施

气候变化不仅会给国家的生存环境、社会安全、经济稳定带来非冲突性威胁，也会因引发社会、经济问题而直接或间接给国家传统安全造成威胁。不同情形下东道国的气候安全利益在何种程度上能够构成 IIAs 安全例外条款中的基本安全利益，应当分别加以分析。

首先，对于非传统安全危机在何种程度上能够被认定为涉及基本安全利益，仲裁庭持有不同的解释立场和方法。Enron 案、Sempra 案的仲裁庭采取客观主义的解释方法，以“涉及一国的存在和独立”和“面临严重和迫在眉睫的威胁”为基本安全利益的判断因素，认为阿根廷经济危机导致的公共秩序混乱和社会动荡仍在政府可控范围之内，并未达到足以危及安全利益的程度⑳。LG&E 案、Lee−Chin 案的仲裁庭采取结果导向的解释方法[24]，前者将经济危机的严重程度与军事侵略类比，认为引发经济、政治和社会领域的全面崩溃足以构成基本安全利益㉑；后者则将整个国家都必须调配资源、采取应对和适应措施作为判定标准㉒。尽管上述案件的裁判结果不同，但仲裁庭都将东道国经济、政治和社会的整体稳定作为基本安全利益认定的关键要素，并将危机的不可控性、社会全面崩溃的严重性、应对的紧迫性等作为认定基本安全利益遭到严重威胁的标准。与 Enron 案等案件中的经济危机类似的是，气候变化也会给国家安全带来系统性风险，具体表现为对经济、社会、国土安全、人类健康和生活条件产生的广泛影响和连锁效应；风险具有持续性和累积性，到达某一临界点会迅速引发极端严重的灾害[25]。尤其对于气候脆弱性较强的国家，这种系统性风险的严重程度会更高。例如气候变化使得小岛屿国家遭受极端天气、海岸侵蚀、水污染等严重后果，为最不发达国家和发展中国家带来了粮食短缺、基础设施破坏、经济衰退、疾病传播等风险，已对这些国家的领土完整、政治稳定、社会秩序造成了需要采取紧急措施加以控制的多重威胁㉓。因此，不论从客观主义还是结果导向的角度解释基本安全利益，东道国在某些气候紧急情形下采取的必要措施都可能被纳入安全例外条款的适用范围。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　既有争端解决实践中涉及安全例外条款的案件[19]

案件名称	涉及的安全利益	裁判逻辑	安全例外抗辩是否成功	裁判机构
CMS 案	经济安全	所涉条款不属于自裁性条款，仲裁庭需进行实质性审查：(1)协定目标是否排除了东道国行为的必要性；(2)经济危机是否可以构成基本安全利益；是否存在严重和迫在眉睫的危险；(3)东道国采取的措施是否是维护安全利益的唯一途径；(4)东道国的行为是否损害了所负义务相对国家的基本利益；东道国是否促成危急情况的发生	否	国际投资仲裁庭
Enron 案		所涉条款不属于自裁性条款，仲裁庭借鉴习惯国际法中危急情况的审查标准，认为所涉措施需满足：(1)保障基本安全利益免受严重和迫在眉睫的危险的唯一途径；(2)没有损害所负义务相对国家或国际社会整体的基本利益；(3)没有东道国自身的促成因素	否，但相关部分的仲裁裁决被临时委员会撤销	
Sempra 案			否，但仲裁裁决被临时委员会撤销	
LG&E 案		(1)东道国基本安全利益是否受到威胁；(2)东道国为维护基本安全利益而采取的措施是否是必要的	部分时间段的措施成功	
Continental Casualty 案		(1)东道国的经济、政治和社会危机是否涉及基本安全利益；(2)所涉条款是否属于自裁性条款；(3)所涉措施对于保护东道国的基本安全利益是否是必要的；(4)仲裁庭适用所涉条款评估东道国行为的影响	部分措施成功	
El Paso 案		(1)东道国基本安全利益是否受到威胁；(2)东道国为维护基本安全利益而采取的措施是否是必要的；(3)东道国是否促成危急情况的发生	否	
Mobil 案		(1)东道国是否促成危急情况的发生；(2)东道国基本安全利益是否受到威胁；(3)东道国为维护基本安全利益而采取的措施是否是必要的	否	
CC/Devas 案	电信安全	(1)东道国所涉措施是否涉及基本安全利益的维护；(2)是否旨在以及能够维护基本安全利益	是，但仲裁庭只认定东道国采取所涉措施60%的目的是出于维护其基本安全利益	
Deutsche Telekom 案		(1)东道国所涉措施是否构成对投资的禁止或限制；(2)是否涉及基本安全利益的维护；(3)是否在维护基本安全利益的必要限度内	否	
Lee-Chin 案	环境安全	(1)所涉环境危机能否构成国家安全利益(national security interests)，即所涉环境危机是否具有全国性；或者，即使在范围上不具有全国性，所涉环境危机是否会产生相当程度的全国性影响；(2)东道国所涉措施能否被定性为保护国家安全利益的必要措施	否	
Seda 案	打击有组织犯罪、洗钱和毒品贩运	(1)东道国所涉措施是否涉及基本安全利益的维护；(2)是否是为了维护基本安全利益而善意采取的措施	是	
俄罗斯货物过境案	俄罗斯在克里米亚事件及相关俄乌冲突的背景下采取制裁措施	(1)所涉措施是否是“在战争或国际关系中的其他紧急情况下采取的”；(2)采取该措施是否是为了“保护其基本安全利益”；(3)东道国是否认为该措施对于保护其基本安全利益是“必要”的	是	WTO 专家组
美国对钢铁和铝产品措施案	美国认为在全球钢铁和铝产能过剩的背景下，钢铁和铝的大量进口导致国内相关产业和经济疲软	所涉措施是否是“在战争或国际关系中的其他紧急情况下采取的”	否，但美国提起上诉	
沙特阿拉伯知识产权保护措施案	沙特阿拉伯为保护公民、领土和政府免受恐怖主义和极端主义的威胁而断绝与卡塔尔的所有外交和经济联系	(1)所涉措施是否是“在战争或国际关系中的其他紧急情况下采取的”；(2)采取该措施是否是为了“保护其基本安全利益”；(3)东道国是否认为该措施对于保护其基本安全利益是“必要”的	部分措施成功(争端双方在不通过专家组报告的情况下终止了争端)	
美国原产地标记要求案	美国认为“香港局势”对其国家安全构成威胁	所涉措施是否是“在战争或国际关系中的其他紧急情况下采取的”	否，但美国提起上诉	

资料来源：作者根据涉及安全例外条款的国际投资仲裁裁决和 WTO 专家组报告整理。

中国知网　https://www.cnki.net

其次，对于传统国家安全利益的认定，俄罗斯过境运输案的专家组认为 GATT 第 21 条中的“战争”指发生在国家之间、一国政府与武装团体或武装团体之间的武装冲突；“国际关系中其他紧急情况”则指除了(潜在)武装冲突之外的国际紧张局势、整个国家陷入普遍不稳定等涉及国家的国防和军事利益以及维护法律和公共秩序利益的局势㉔。相关措施满足这一例外情形需要考量两个因素：一是国际紧急情况必须是客观存在的事实，二是措施的采取与紧急情况的发生存在时间一致性㉕。最终，专家组基于联合国大会的有关决议以及部分国家对俄罗斯实施制裁的事实，认定克里米亚危机构成国际关系中的紧急情况㉖。就气候变化而言，其对武装冲突或紧张局势的作用机制表现为气候变化—生态环境恶化—社会问题加剧—武装冲突或紧张局势发生的传导链条[11]。虽然气候变化本身并非武装冲突或紧张局势发生的直接原因，但国家为应对气候危机采取的具体气候变化措施可能加剧或最终导致冲突爆发，危及国家的传统安全利益。另外，国际社会已日益认识到气候变化对非洲、南亚、中东等地区构成的安全威胁，例如安理会在第 2349(2017)号决议中分析乍得湖流域面临安全挑战的根本原因时，明确了气候、生态变化等因素对该地区稳定的不利影响，强调各国政府和联合国需要制定有关这些因素的适当风险评估和风险管理战略。如果东道国主张是在冲突或紧张局势发生期间采取的气候变化措施以维护其国防和军事利益，安理会的相关决议或能成为仲裁庭认定国际紧急情况的客观证据。

2. 安全事项之二：东道国在非气候紧急情况下采取的气候变化措施

在印度电信双案和 Seda 案中，仲裁庭对东道国在非紧急情况下采取的措施是否涉及基本安全利益的判定存在两个要点：一是遵循基本安全利益的客观含义，将其解释为绝对必要的、涉及国家安全核心和本质的利益，并注重所涉措施的(准)军事因素㉗。如印度电信双案的仲裁庭认可印度政府为国防和准军事的通信需求而保留 S 波段频谱旨在保护其基本安全利益；Seda 案的仲裁庭明确哥伦比亚为保护公民免受准军事组织的威胁而打击有组织犯罪、洗钱和毒品贩运，关涉其公共安全、国家安全和社会经济稳定，因而构成基本安全利益。二是支持东道国采取安全措施的时间节点提前。正如印度政府将 S 波段频谱的不合理分配称为“安全角度的不合理风险”，基于印度军事机构对 S 波段频谱的真正需求，CC/Devas 案的仲裁庭认为预防频谱的商业用途给印度国防和准军事通信需求带来的风险涉及其基本安全利益㉘；Seda 案的仲裁庭认同哥伦比亚检察官扣押投资者涉嫌有组织犯罪、洗钱和毒品贩运的财产的预防措施是对其基本安全利益的维护㉙。可以看出，相较于东道国缓解紧急情况的应对性(reactive nature)，印度电信双案和 Seda 案中东道国实施的措施具有风险预防性(precautionary nature)⑰。

以上述仲裁庭的裁判逻辑为依据，东道国为预防气候变化对其军事职能以及气候适应性基础设施产生威胁而采取的措施，存在构成安全例外情形的可能性。首先，根据美国一家研究机构的调查，气候变化会引发三个方面的军事性破坏：①缩短武器系统和平台的使用周期，增加维护难度；②破坏甚至直接淹没军事基础设施和基地；③造成的自然灾害、能源供应短缺等会影响军事行动和能力㉚。当气候变化对一国的关键武器系统、军事基础设施或者军事行动造成潜在的、实际的风险时，东道国为预防其军事职能受减损而采取的有关气候措施会融入传统安全因素，从而触及国家安全核心和本质利益。值得注意的是，为了确保安全例外条款的适用在投资保护目标和国家安全利益之间实现平衡，不能认为所有与军事有关的气候变化措施都会涉及基本安全利益的维护，仲裁庭需要研判军队行使其维护国家主权和领土完整免受内外威胁的职能受到何种程度的减损[26]。其次，由于气候变化的不利影响是长期、严重且不可逆的，气候变化适应措施不仅强调通过改善基础设施、自然生态系统和管理系统以降低气候变化的既有影响，而且注重提高国家的风险防范和应对能力，兼具应对性和预防性[27]。特别对于气候脆弱性较强的国家，确保应对气候变化的关键基础设施、资源、管理系统等涉及国家生存和发展的核心，对其维护基本安全利益具有重要意义。如果东道国能够证明其是在面临实际的、迫在眉睫的风险时采取的保障其关键基础设施等气候适应措施，可以认定相关措施与维护其基本安全利益

中国知网 https://www.cnki.net

有明确和直接的关系，满足安全例外条款的事项条件[28]。

(三) 气候变化措施符合安全例外条款的关联性条件

在安全例外条款的适用中，所涉措施与实现 IIAs 允许的合法政策目标之间的关联性是影响案件结果的另一重要因素，仲裁庭会根据不同的条款措辞采用严格程度不同的审查标准。既有争端解决实践中涉及的关联性条件的相关措辞及审查标准主要包括三种(见表 2)。

表 2　既有争端解决实践中涉及安全例外条款关联性条件的措辞类型及审查标准

措辞类型	相关案例	审查标准	裁判机构
necessary for	CMS 案、Enron 案、Sempra 案	习惯国际法中的唯一性标准㉛	国际投资仲裁庭
	LG&E 案	否定唯一性标准，认为国家可采取多种措施	
	El Paso 案、Mobil 案	国家是否促成了威胁基本安全利益的情形的出现	
	Continental Casualty 案、Deutsche Telekom 案	最低限制性替代措施标准	
directed to	CC/Devas 案	相关措施是否与促进基本安全利益的维护相关	
it considers necessary for	Seda 案	善意履约义务下的最低合理性要求	WTO 专家组
	俄罗斯货物过境案、沙特知识产权保护措施案	善意履约义务下的最低合理性要求	

资料来源：作者根据涉及安全例外条款的国际投资仲裁裁决和 WTO 专家组报告整理。

在 LG&E 案中，仲裁庭没有明确“必要的”(necessary for)的具体审查标准，但否认所涉安全例外条款对相关措施的唯一性要求，认为一个国家在只能紧急行动以维持公共秩序或保护基本安全利益的情况下采取的必要措施可以有多种㉜。El Paso 案和 Mobil 案的仲裁庭依据《维也纳条约法公约》第 31.3.c 条规定的条约解释方法，认为习惯国际法中的危急情况属于解释 IIAs 安全例外条款的“有关国际法规则”，从而借鉴了其适用要件之一，即国家不得以作为或不作为的方式促成其主张所涉措施的合法性时所依赖的危急情况㉝。Continental Casualty 案的仲裁庭则基于所涉安全例外条款的范式可溯源至 GATT 一般例外条款而借鉴了 WTO 专家组采取的“最低限制性替代措施”(least restrictive alternative measures)标准，即审查所涉措施是否对维护基本安全利益具有贡献以确保两者之间存在真正联系，以及是否有其他限制更少的、合理可行的替代措施㉞。这一标准同样被 Deutsche Telekom 案的仲裁庭所采用。在审查是否有其他替代措施时，这两个仲裁庭只限于分析具有合理可行性的措施，与习惯国际法下确定“唯一办法”时只考虑替代措施的存在与否形成鲜明对比。

整体而言，国际投资仲裁庭对“必要的”的审查标准从措施的唯一性、东道国无促成因素转变为更灵活精细的“最低限制性替代措施”标准，对东道国自主行使监管权展现出更多尊重，也进一步增强了东道国援引安全例外条款合法化其气候变化措施的可能性。气候变化的成因、后果都具有多样性和复杂性，东道国通常会采取多种相互作用、相互配合的气候变化措施，使得单项措施对维护气候安全利益的贡献短期之内难以衡量，且要求东道国除了采取的措施之外没有其他替代办法也是不现实的㉟。而根据“最低限制性替代措施”标准，东道国实施的气候变化措施如果能够实质性或潜在地保护其安全利益，以及在具有可行性的多种选择中对投资的限制和影响最小，即可满足必要性的审查条件。

CC/Devas 案是当前投资仲裁实践中唯一涉及“旨在”(directed to)这一关联词解释的案件。在裁决中，仲裁庭驳回了 CC/Devas 主张印度政府的措施应当满足必要性要求的观点，认为所涉安全例外条款并未提及“必要的”这一要求，因而具有较强的自我判断性质，仲裁庭只需审查相关措施是否与促进维护基本安全利益相关(related to)㊱。Seda 案和 WTO 争端解决案件中适用的关联性措辞为“其认为

中国知网　https://www.cnki.net

必要的”，其中“其认为”的自裁性用语赋予了缔约方更多的自主权。Seda 案的仲裁庭和俄罗斯货物过境案的专家组都指出，对相关措施的“必要性”判定属于缔约方的自裁权范围，仅受到善意履约义务下(最低)合理性要求的限制，即应当确定有关措施是否与紧急情况相去甚远或毫不相关，以至于不可能认为缔约方实施这些措施是为了保护因紧急情况而产生的基本安全利益㊲。总体而言，对于适用“旨在”和“其认为必要的”关联性要求的案件，仲裁庭都是在尊重东道国自裁权的基础上进行客观审查的，为东道国根据本国情况善意采取适应性、多样化的气候安全措施预留了较大的灵活空间。

四、气候变化措施适用 IIAs 安全例外条款的限制

IIAs 安全例外条款在协定文本和解释适用上的新发展已经为东道国援引安全例外条款合法化其气候变化措施提供了可行性。然而，由于气候变化措施的类型和范围十分广泛，加之安全例外条款在协定文本和解释适用中的主观因素的增强，仲裁庭对气候变化措施适用安全例外条款的审查判断具有一定的复杂性和不可预测性。在此背景下，亟须完善安全例外条款的协定文本和适用规则，以限制和明确条款的适用范围，使其在保障东道国气候公共利益的同时维持例外适用和规制平衡的应然状态。

(一) 限制的出发点

作为非传统安全领域中的重要议题，气候变化既具有非传统安全的长期性、跨国性等共同特质，又有其复合性、联动性等独特之处，使得东道国的气候变化措施一旦成功援引安全例外条款，将会产生双重影响。一方面，安全例外条款的适用能够为国家在基本安全利益受到气候变化威胁时自主采取规制措施打开“违约之门”；另一方面，这种适用也存在进一步模糊安全例外条款适用门槛和边界的风险。具体而言，与公共卫生、数据安全的单一性不同，气候变化的复合效应使其与其他非传统安全相互牵连、相互融合。在一定意义上，东道国的气候措施成功援引安全例外条款意味着其在国际投资法治中实现气候变化的安全化。这不仅会对东道国的气候安全化进程产生重大影响，也会激励其他国家援引安全例外条款推进生态、能源等其他关联问题的安全化[3]，从而加速国家安全概念的扩张甚至泛化，削弱安全例外条款的“例外”性质，使得投资者利益保护和东道国规制权再次面临失衡风险。

另外，随着气候变化及其影响的显著加深，各国逐渐意识到气候变化在全球性议题以及国家安全和国际安全领域中日益提升的重要性。部分国家也开始基于国内外因素的战略考量推行气候变化安全化，不仅将气候安全议题视为政党竞争的手段之一，更将其作为扩大国际政治影响力、争夺国际话语权和引领全球治理体系改革和建设的载体，使得气候变化措施与地缘政治经济竞争交织互动，具有较强的政治属性[29]。加之部分气候变化措施的预防性和安全例外条款本身的建设性模糊，仲裁庭在识别东道国气候变化措施的目的性和关联性方面存在一定的不确定性，使得一些国家以应对气候变化和维护国家安全为外观目的、以保护主义和单边主义为内核的“气候变化措施”有隙可乘。

需要明确的是，立足于气候变化措施安全例外抗辩对安全例外条款的适用门槛和边界产生的潜在影响而加以限制，并不意味着对东道国气候规制权的压缩，而是基于气候变化措施的独特性以及各国援引安全例外条款自我克制态度逐渐松动的背景的现实选择。同时，这也是协调东道国气候公共利益和投资者私人利益、兼顾东道国气候规制权和全球气候治理利益的必然要求。明确、合理的适用界限有利于缓解气候变化措施的“政治性”内核和“法律性”规制之间的张力，使安全例外条款真正成为缔约方自主采取气候安全政策的主权表达，而非进一步加剧条款适用边界模糊和例外性质异化的工具。从本质上讲，对气候变化措施适用安全例外条款的限制是对国际投资场域中经济利益和安全利益的平衡，对于协调非传统安全时代国家安全演变需求与国际投资法目标的实现同样具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

(二) 文本改进：制定“平衡型”IIAs 安全例外条款

当前安全例外条款呈现出自裁性强化、国家安全利益范畴扩张、关联性标准宽松化的发展特征，这也使得其存在解释上的不确定性。对此，应当通过主客观因素的再平衡来规制安全例外条款的适用空间，在给予东道国维护本国气候安全利益的自裁权为其提供有保障的气候安全例外的同时，通过仲裁庭的客观审查对其适用施以限制，减少对投资者利益的减损。

1. 将气候变化措施纳入安全例外情形

在 IIAs 的条约实践中，缔约方如果选择将某项情形明确列举在安全例外条款中，则意味着其一致同意将该情形作为投资自由化和投资保护例外的合法政策目标[30]。采用此种规定方式的安全例外条款虽然在适用范围上有所限制，但较之概念式安全例外条款更具有确定性和可预期性，能够更好地均衡投资利益和东道国的安全利益。作为可持续发展的重要政策目标之一，气候行动早已受到国际社会的广泛关注。UNCTAD 发布了多篇关于气候变化与国际投资体制的报告，各国也越来越多地在 IIAs 中纳入有关气候行动的条款。在气候变化安全化在全球投资治理与气候治理中的重要性日渐凸显的背景下，将气候变化措施纳入 IIAs 中安全例外的具体情形，不仅能够彰显气候安全利益的优先价值，缓解气候治理与投资保护的冲突，还有助于预防气候安全在争端解决实践中被任意解释和扩充，增加气候变化措施适用安全例外条款的可操作性[31]。具体而言，缔约方可以明确将保护气候安全利益列为 IIAs 中的安全例外情形，并达成对气候安全措施范围的一致意见，例如规定“本协定中任何条款均不得解释为阻止缔约方采取其认为对保护与气候变化有关的基本安全利益所必要的行动。为进一步明确，这些行动可能包括为应对极端天气、严重粮食短缺、沿海洪水、疾病暴发、人口流动采取的措施”[32]。

2. 纳入必要性条件的客观审查标准

在明确安全例外情形涵盖气候变化措施的前提下，安全例外条款对关联性条件的规定将成为判定气候安全措施和非气候安全措施的关键因素。从既有争端解决实践来看，WTO 专家组和投资仲裁庭对“其认为必要的”的解释相对一致，CC/Devas 案的仲裁庭对“旨在”的审查标准也易于理解和适用。而投资仲裁庭对于“必要的”尚未形成统一的审查标准，使得采用该措辞的安全例外条款的适用缺乏明确性和可预见性。从现有仲裁实践来看，在适用“必要的”这一关联词的 ISDS 案件中，Continental Casualty 和 Deutsche Telekom 案的仲裁庭采取的“最低限制性替代措施”标准较为契合国际投资仲裁体制和非传统安全时代东道国气候规制权的保障需求。一方面，该标准在借鉴 WTO 专家组对于一般例外条款必要性审查标准的基础上，排除了“权衡各种因素”这一步骤，避免了仲裁庭在缺乏公法争端方面的法律专业性以及对缔约方采取所涉气候措施背景缺乏了解的情况下，对缔约方行使规制权的行为作出价值判断和过多干预[33]；另一方面，该标准分为两步先后审查所涉措施对维护基本安全利益的贡献以及是否存在限制更小的替代措施，具有较强的实操性，且不再强调相关措施在实现相关政策目标方面的唯一性，为包括气候变化措施在内的非传统安全提供了适用安全例外条款的空间。

鉴于仲裁庭对必要性的解释缺乏一致性，印度在其 2016 年 BIT 范本中为一般例外条款中必要性要求的审查提供了明确指引，规定仲裁庭在判断一项措施是否“必要”时，应考虑东道国是否有合理可行的、限制性较小的替代措施。缔约方在缔结 IIAs 安全例外条款时也可以参照这种思路，以脚注或者附件形式澄清必要性审查采取“最低限制性替代措施”标准，从而为仲裁庭在争端解决中适用这一标准提供规则依据，为缔约方和投资者提供更大的法律确定性。值得注意的是，在审查所涉措施对维护基本安全利益的贡献时，Continental Casualty 案的仲裁庭认为所涉措施应当对目标的实现有实质性(material or decisive)贡献；Deutsche Telekom 案的仲裁庭则侧重于审查所涉措施是否主要针对(principally targeted)目标的实现，将措施的潜在贡献也考虑在内，允许相关措施的实施和结果之间存在时间差[26]。考虑到部分气候变化措施的成效需要一定时间的系统评估，Deutsche Telekom 案的仲裁

中国知网 https://www.cnki.net

庭采取的标准具有一定可行性和合理性，可以作为各国明晰“最低限制性替代措施”标准的参照。

3. 增加安全例外条款适用的限制条件

安全例外条款适用的关联性条件旨在保证相关措施与所要实现的政策目标之间的因果关系，尤其在适用采纳“适当的”“旨在”等术语的安全例外条款时，仲裁庭只需要审查相关措施与基本安全利益的关联，没有最低限制性的审查步骤。换言之，一项气候变化措施满足关联性条件仅仅意味着其有助于东道国气候安全利益的维护，并不能排除以气候安全为幌子而实行保护主义的措施。那些有意以国家安全为名掩盖非法政治目的的国家，可能将该条款作为限制投资、实现政治目标的有利手段。因此，设置安全例外条款适用的限制条件，能够对东道国实施气候变化措施的真实意图进行“二次审查”，是遏制缔约方保护主义的“控制阀”，也是防止东道国滥用该条款的关键限制方式[34]。

IIAs 的条约实践对安全例外条款适用的限制条件有两种规定方式：①规定合理、善意、不构成武断或不合理歧视以及对投资的变相限制、不违反或逃避协定项下的义务等实体性限制条件㊳；②规定通知义务等程序性限制条件㊴。根据 WTO 争端解决实践的经验，“变相限制”特别是“变相”(disguised)这一术语意在揭示某项措施隐蔽的保护主义意图，这可以通过其设计、框架和结构识别出来㊵。为明确约束气候变化措施的实施方式，缔约方可以在安全例外条款中规定相关措施不能构成武断、不合理歧视或对投资的变相限制。另外，要求东道国将所采取的气候变化措施的负责部门、法律依据、措施内容等情况通知其他缔约方，能够在措施实施前或初期为缔约方提供一定的谈判空间，避免对投资者产生进一步的负面影响[35]，通过“实体+程序”的双重限制条件为安全例外条款的合理适用提供保障。

(三) 实践优化：完善 IIAs 安全例外条款的解释框架

从既有投资仲裁实践可以看出，即使仲裁庭对安全例外条款适用要件的审查标准作出解释，其在具体适用的过程中仍然受到仲裁庭对东道国监管权尊重程度和对协定文本解释路径的影响，导致该条款的适用存在模糊性和不确定性。对此，应当完善仲裁庭在投资争端实践中对安全例外条款的解释方法，为仲裁庭在裁决主权国家安全问题方面的司法能动划定适当框架。

1. 合理运用演进解释方法解释基本安全利益

在未明确列举安全例外情形的条款下，能否将气候变化解释为基本安全利益将是仲裁庭在适用安全例外条款时面临的首要问题。在仲裁实践中，仲裁庭在以狭义解释和客观文本主义解释限制基本安全利益范围的同时，通过演进解释的方式表现出对其内涵的开放态度[36]。根据《维也纳条约法公约》规定的条约解释的一般规则，仲裁庭对基本安全利益进行演进解释从而认同经济安全的理据主要包括：①协定的目标和宗旨并未明确排除；②平衡投资者私人利益和东道国保护本国人民免受内外部威胁的主权利益；③国际社会包括当事方的条约惯例对二战后国家安全概念扩张至政治及军事安全之外的普遍认识；④《联合国宪章》《国际货币基金组织协定》等对实现国家经济政策目标的追求㊶。

对于气候安全而言，IIAs 同样未排除东道国在气候变化情形下的安全例外抗辩权，且已有缅甸-新加坡 BIT 等 IIAs 在序言中重申东道国实现可持续发展、保护环境和气候等公共利益的规制权。在有关气候安全的国际法规则基础方面，鉴于国家安全从传统安全到人类和社会发展安全的范式转变，有学者提出将《经济、社会、文化权利国际公约》作为解释基本安全利益的依据[37]。该公约规定缔约方有义务采取必要措施确保其公民获得相当的生活水准、达到最高的体质和心理健康标准等。当气候变化严重威胁缔约方满足公民持续和基本生活需求的能力时，该公约可以作为东道国主张保障其基本安全利益的依据[37]。另外，安理会也在部分地区的安全受到气候变化的威胁方面达成了共识，如 2018 年 6 月通过的第 2423(2018)号决议基于气候变化、生态变化等因素对马里稳定的不利影响，强调马里政府和联合国在马里的各项活动、方案和战略必须适当考虑这些因素所涉及的安全问题。随着国际社会在气候变化对国家安全、国际安全产生威胁方面的共识程度不断加深，相关国际法规则、国际

中国知网 https://www.cnki.net

组织的决议可能也会随之增加，仲裁庭应当注重通过演进解释将气候变化纳入基本安全利益范围的国际法规则基础。诚然，并非所有的气候变化威胁都关涉一国的安全利益，仲裁庭仍需对气候变化适用安全例外条款保持高度克制和审慎态度，以整体性、复合性的审查方式综合分析气候变化给东道国的生态、社会、军事和政治领域带来的影响，并将东道国的国情、应对气候变化的能力等其他因素纳入考量，从而评估气候变化对东道国的领土完整、独立生存和国内和平等核心安全利益造成的威胁。

2. 适用善意原则规制安全例外条款的解释空间

在安全例外条款自裁性增强的趋势下，明确善意原则的审查标准对限制气候变化措施适用该条款具有重要意义。尤其是对于没有规定不能构成武断等限制性条件的安全例外条款，善意审查更是防止其滥用的有效工具。在当前争端解决实践中，WTO 专家组和仲裁庭在适用善意原则时并未对其作出清晰阐述，导致其适用范围和事项存在不一致性和不确定性。WTO 专家组和 Seda 案的仲裁庭不仅在分析管辖权、安全例外条款的自裁性时运用了善意原则，在解释“基本安全利益”“必要性”等概念时也有所体现[42]；LG&E 案的仲裁庭认为对适用自裁性安全例外条款的善意审查与对适用非自裁性安全例外条款的实质性审查没有显著区别，都需要分两步审查所涉事项和措施的必要性[43]；而 Continental Casualty 案的仲裁庭认为只需确定阿根廷在经济危机构成基本安全利益的情况下善意援引安全例外条款，无须对措施的必要性作进一步审理[44]。

为规制东道国在自裁性安全例外条款下的气候监管空间，可以延续 WTO 专家组和 Seda 案仲裁庭的立场，将善意审查贯穿安全例外条款适用和解释的整个过程。另外，仲裁庭应当根据善意原则的基本要素具体化审查标准：①缔约方是否按照诚实、公平的方式行事，例如是否存在非安全性动机、是否宣布国家气候紧急状态、是否有国内法律依据、是否确保决策过程的公众参与和透明度等；②缔约方气候安全利益受到严重威胁是否有合理、客观的依据，例如一个小岛屿国家依据科学测量或预测的海平面上升而建造海岸防护工程加以应对，即使存在与之相异的科学数据或结果，也应当认为该国有作出决定的合理依据[38]。不同于对非自裁性安全例外条款的实质性审查，这种善意审查注重指引仲裁庭形成实体性和程序性审查相结合、以程序性审查为导向的审查方式，其审查过程一定意义上只是对缔约方作出决策的客观依据的二次确认，从而在督促缔约方审慎、合理决策的同时，减少仲裁庭作为裁判机构的事后主观判断和倾向于投资者的立场对缔约方主权行为的过度干涉。

五、结语

为回应公共卫生、网络数据等多元化非传统安全因素渗入国际投资法治，各国已强化安全例外条款的缔结实践和解释适用。从价值定位来看，安全例外条款已允许东道国在保障人类和社会发展安全时破除投资保护义务的合法性约束；从适用方式来看，安全例外条款在依赖缔约方自我约束的同时，在投资仲裁实践中逐渐形成了“缔约方自裁+仲裁庭审查”的双层适用机制，已成为缓解投资者利益和东道国日益凸显的气候安全利益之间张力的可行性路径。为确保安全例外条款在回应非传统安全时代需求的同时回归例外适用的应然状态，各国可以应对气候变化的安全化为切入点，继续优化安全例外条款的协定文本和解释框架，抵消以气候变化为代表的非传统安全以及国家安全泛化给安全例外条款的解释和适用带来的不可预测性，避免其成为各国参与地缘政治竞争、实现自身政治利益的工具。

中国目前纳入安全例外条款的 IIA 不仅数量较少，且这些条款在所处章节、自裁性、关联性条件、适用限制等方面存在显著差异，体现出中国尚缺乏对规范制定安全例外条款的应有重视。总体国家安全观是中国新时代国家安全工作的根本遵循，强调统筹发展和安全、外部安全和内部安全、传统安全

中国知网　https://www.cnki.net

和非传统安全的丰富内涵和系统思维。这不仅有利于增进对气候变化安全影响广泛性和联动性的认识，也为中国增强自身在国际投资场域抵御国家安全泛化和保护主义的能力提供了实践指引。基于此，中国一方面应当完善安全例外条款的条约实践，通过明确气候变化为安全例外情形之一、增加条款适用的限制条件等方式形成平衡型安全例外条款的中国范式，抑制安全例外条款衍化为政治工具的风险；另一方面也应当注重强化海外投资应对东道国气候变化安全风险预警与防控机制建设，以较高的安全能力水平作为追求海外投资利益的保障，系统性构建我国应对气候变化安全化、实现发展和安全良性互动的投资治理新模式。

注释：

① The Parliament of the United Kingdom. The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an Interdependent World. 2008. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c68abed915d696ccfc92a/7291.pdf (last visited April 20, 2025).

② The White House of the United States. National Security Strategy. May 2010. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf (last visited April 20, 2025).

③ The United Nations Environment Programme. Livelihood Security: Climate Change, Migration and Conflict in the Sahel. 2011. https://publications.iom.int/system/files/pdf/unep_sahel_en.pdf (last visited April 20, 2025).

④ 其中阿根廷经济危机系列案件包括 CMS v. Argentina 案(以下简称 CMS 案)、Enron v. Argentina 案(以下简称 Enron 案)、Sempra v. Argentine 案(以下简称 Sempra 案)、LG&E v. Argentina 案(以下简称 LG&E 案)、Continental Casualty v. Argentine 案(以下简称 Continental Casualty 案)、El Paso v. Argentina 案(以下简称 El Paso 案)、Mobil v. Argentina 案(以下简称 Mobil 案)；印度电信双案包括 CC/Devas v. India (I)案(以下简称 CC/Devas 案)、Deutsche Telekom v. India 案(以下简称 Deutsche Telekom 案)。

⑤ Discovery Global v. Slovakia, Respondent’s Counter-Memorial, ICSID Case No. ARB/21/51, March 31, 2023, para.243. 值得注意的是，在之后提交反驳意见(Respondent’s Rejoinder)、庭审等仲裁程序中，斯洛伐克未针对安全例外条款的适用作进一步回应和阐述，因此仲裁庭在仲裁裁决中认为斯洛伐克已放弃这一抗辩理由，也未对安全例外条款进行具体解释。

⑥ Discovery Global v. Slovakia, Claimant’s Reply, ICSID Case No. ARB/21/51, September 18, 2023, paras.223, 225, 226.

⑦ Mobil v. Argentina, Separate Opinion of Professor Antonio Remiro Brotons, Arbitrator, ICSID Case No. ARB/04/16, March 27, 2013, para.41.

⑧ 例如约旦−新加坡 BIT(2004)第 19 条、加拿大−几内亚 BIT(2015)第 18.4 条、巴西−印度 BIT(2020)第 24.1 条。

⑨ 例如立陶宛−土耳其 BIT(2018)第 6 条采用“公共安全”的表述；墨西哥−瑞典 BIT(2000)第 18 条采用“国家安全”的表述；意大利 2003 年 BIT 范本第 5.2 条采用“国家利益”的表述；泛非投资法典第 14 条采用“国家安全利益”的表述。

⑩ Seda v. Colombia, Award, ICSID Case No. ARB/19/6, June 27, 2024, para.642.

⑪ Organization for Economic Co-operation and Development. Security-Related Terms in International Investment Law and in National Security Strategies. 2009. https://one.oecd.org/document/DAF/INV/WD(2009)1/en/pdf (last visited April 20, 2025).

⑫ Department of Climate Change of Government of Vanuatu. Declaration of Climate Emergency Approved Unanimously by the Parliament of Vanuatu. May 31, 2022. https://docc.gov.vu/index.php/resources/news-events/news/120-declaration-of-climate-emergency-approved-unanimously-by-the-parliament-of-vanuatu# (last visited April 20, 2025).

⑬ 联合国政府间气候变化专门委员会：《气候变化与土地：IPCC 关于气候变化、荒漠化、土地退化、可持续土地管理、粮食安全及陆地生态系统温室气体通量的特别报告(决策者摘要)》，2019 年。

⑭ 例如安哥拉−日本 BIT(2023)第 16.2 条采用“包括”(including)的表述；印度−白俄罗斯 BIT(2018)第 33.1 条、印度−吉尔吉斯斯坦 BIT(2019)第 33.1 条采用“包括但不限于”(including but not limited to)的表述。

⑮ Continental Casualty v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/03/9, September 5, 2008, paras.193, 196.

⑯ 例如秘鲁−新加坡 BIT(2003)第 11 条采用“directed to”的表述；哥伦比亚 2007 年 BIT 范本第 2.3 条采用“intended to”的表述；中国−印度 BIT(2006)第 14 条采用“for”的表述。

⑰ United Nations Conference on Trade and Development(以下简称 UNCTAD). The Protection of National Security in IIAs. 2009. https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia20085_e n.pdf (last visited April 20, 2025).

中国知网 https://www.cnki.net

⑱ United Nations Development Programme. What Is Climate Change Adaptation and Why Is It Crucial. January 30, 2024. https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/what-climate-change-adaptation-and-why-it-crucial (last visited April 20, 2025).

⑲ 此表仅统计了涉及安全例外条款且有仲裁裁决的 ISDS 案件和有 WTO 专家组报告的 WTO 争端案件，未包含国际法院等其他裁判机构审理的相关案件。

⑳ Enron v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/01/3, May 22, 2007, paras.306-307; Sempra v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/02/16, September 28, 2007, paras.348-349.

㉑ LG&E v. Argentina, Decision on Liability, ICSID Case No. ARB/02/1, October 3, 2006, paras.231, 238, 257.

㉒ Michael Anthony Lee-Chin v. Dominican Republic, Final Award, ICSID Case No. UNCT/18/3, October 6, 2023, para.254.

㉓ Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007-Impacts, Adaptation and Vulnerability. 2007. https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg2/ (last visited April 20, 2025).

㉔ Russia-Measures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, April 5, 2019, paras.7.72-7.76.

㉕ Russia-Measures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, April 5, 2019, paras.7.70, 7.77.

㉖ Russia-Measures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, April 5, 2019, paras.7.122-7.123.

㉗ CC/Devas v. India, Award on Jurisdiction and Merits, PCA Case No. 2013-09, July 25, 2016, paras.243, 356; Deutsche Telekom v. India, Interim Award, PCA Case No. 2014-10, December 13, 2017, para.281; Seda v. Colombia, Award, ICSID Case No. ARB/19/6, June 27, 2024, paras.642, 765.

㉘ CC/Devas v. India, Award on Jurisdiction and Merits, PCA Case No. 2013-09, July 25, 2016, paras.151, 315, 354.

㉙ Seda v. Colombia, Award, ICSID Case No. ARB/19/6, June 27, 2024, para.792.

㉚ The Center for Naval Analyses. National Security and the Threat of Climate Change. 2007. https://www.cna. org/reports/2007/na tional-security-and-the-threat-of-climate-change (last visited April 20, 2025).

㉛ 这三个案件的仲裁庭均适用习惯国际法中危急情况的分析框架来解释 IIAs 安全例外条款，未对 IIAs 安全例外条款的适用要件作出具体阐述。然而，这两者在适用情形、构成要件、法律位阶等方面存在差异，这种解释方法存在一定问题。参见 CMS v. Argentina, Decision of the *Ad Hoc* Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, September 25, 2007, paras.128-136; Sempra v. Argentina, Decision on the Argentine Republic's Application for Annulment of the Award, ICSID Case No. ARB/02/16, June 29, 2010, paras.197-204.

㉜ LG&E v. Argentina, Decision on Liability, ICSID Case No. ARB/02/1, October 3, 2006, para.239.

㉝ El Paso v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/03/15, October 31, 2011, paras.613-624; Mobil v. Argentina, Decision on Jurisdiction and Liability, ICSID Case No. ARB/04/16, April 10, 2013, paras.1060-1070.

㉞ Continental Casualty v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/03/9, September 5, 2008, paras.192, 196-198.

㉟ Brazil-Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, Report of the Appellate Body, WT/DS332/AB/R, December 3, 2007, para.151.

㊱ CC/Devas v. India, Award on Jurisdiction and Merits, PCA Case No. 2013-09, July 25, 2016, paras.242-243.

㊲ Seda v. Colombia, Award, ICSID Case No. ARB/19/6, June 27, 2024, paras.783, 787; Russia-Measures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, April 5, 2019, paras.7.138-7.139.

㊳ 例如印度–意大利 BIT(1995)第 12 条、荷兰 2019 年 BIT 范本第 11.2 条、土耳其–巴勒斯坦 BIT(2018)第 5.3 条、巴林–日本 BIT(2022)第 18.4 条。

㊴ 例如日本–秘鲁 BIT(2008)第 19.2 条、印度–白俄罗斯 BIT(2018)第 33.2 条。

㊵ European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, Report of the Panel, WT/DS135/R, September 18, 2000, para.8.236.

㊶ CMS v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/01/8, May 12, 2005, paras.359-360; Continental Casualty v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/03/9, September 5, 2008, paras.175, 177; El Paso v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/03/15, October 31, 2011, para.650.

㊷ Russia-Measures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel, WT/DS512/R, April 5, 2019, paras.7.132, 7.138; Seda v. Colombia, Award, ICSID Case No. ARB/19/6, June 27, 2024, paras.650, 655.

㊸ LG&E v. Argentina, Decision on Liability, ICSID Case No. ARB/02/1, October 3, 2006, paras.205, 214.

㊹ Continental Casualty v. Argentina, Award, ICSID Case No. ARB/03/9, September 5, 2008, para.182.

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献：

[1] 金钿. 国家安全论[M]. 北京: 中国友谊出版公司, 2002: 1.

[2] BALDWIN D A. The concept of security[J]. Review of International Studies, 1997, 23(1): 5−26.

[3] HENCKELS C. Whither security? The concept of “essential security interests” in investment treaties’ security exceptions[J]. Journal of International Economic Law, 2024, 27(1): 114−129.

[4] 彭阳. 国际经济治理中的国家安全泛化: 法理剖析与中国应对[J]. 国际法研究, 2022(5): 87−107.

[5] MCDONALD M. Climate change and security: Towards ecological security[J]. International Theory, 2018, 10(2): 153−180.

[6] OELS A. From ‘securitization’ of climate change to ‘climatization’ of the security field: Comparing three theoretical perspectives[M]//SCHEFFRAN J, et al. Climate change, human security and violent conflict: Challenges for societal stability. Berlin: Springer, 2012: 186.

[7] 薄燕, 周逸江. 气候变化安全化成功了吗?: 基于联合国安理会相关会议的分析[J]. 复旦国际关系评论, 2022(2): 52−77.

[8] SINHA A K. Non-precluded measures provisions in bilateral investment treaties of South Asian countries[J]. Asian Journal of International Law, 2017, 7(2): 227−263.

[9] 朱玥. 投资协定“国家安全”条款的范式优化及其适用[J]. 政治与法律, 2024(8): 164−176.

[10] 沈伟. 国际投资协定中的安全例外条款: 全球趋势与中国实践[J]. 比较法研究, 2022(6): 181−198.

[11] 闫伟, 刘爱娇. 气候变化对中东的复合安全威胁及其应对[J]. 世界社会科学, 2023(4): 188−210, 246−247.

[12] YOO J Y, AHN D. Security exceptions in the WTO system: Bridge or bottle-neck for trade and security?[J]. Journal of International Economic Law, 2016, 19(2): 417−444.

[13] 张乃根. 国际经贸条约的安全例外条款及其解释问题[J]. 法治研究, 2021(1): 128−138.

[14] 刘敬东. “国家安全”条款的适用边界及发展动向评析: 以国际贸易投资规则为视角[J]. 法学杂志, 2023, 44(2): 121−138.

[15] PATHIRANA D, MCLAUGHLIN M. Non-precluded measures clauses: Regime, trends, and practice[M]//CHAISSE J, CHOUKROUNE L, JUSOH S. Handbook of International Investment Law and Policy. Singapore: Springer, 2021: 486.

[16] 傅廷中. “安全例外”条款与自由贸易政策的价值冲突与协调[C]//WTO 法与中国论丛(2011 年卷). 北京: 清华大学法学院, 2010: 368−377.

[17] 戴长征, 毛闰铎. 从安全困境、发展安全到总体国家安全观: 当代国家安全理念的变迁与超越[J]. 吉林大学社会科学学报, 2022, 62(6): 29−44, 231−232.

[18] LIANG Y, XIE X Y. The essential security interests clause of international investment treaties in the non-traditional security era: Changes, evolution and justification[J]. China Legal Science, 2022, 10(3): 117−146.

[19] 吴智, 钟韵漪. 中外双边投资协定中的“一般例外”条款研究：以“一带一路”倡议为视角[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2017, 23(4): 18−26.

[20] RANJAN P. Essential security interests in international investment law—A trend towards GATTization[J]. ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, 2024, 39(3): 489−503.

[21] MARSHALL F. Climate change and international investment agreements: Obstacles or opportunities?[R]. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, 2010: 60.

[22] 邓婷婷, 屈丹. 论国家在投资者−国家争端解决机制中的角色转变[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2021, 27(2): 65−80.

[23] 梁咏. 安全视域下投资条约根本安全利益条款的中国范式[J]. 环球法律评论, 2023, 45(2): 18−38.

[24] MOON W J. Essential security interests in international investment agreements[J]. Journal of International Economic Law, 2012, 15(2): 481−502.

[25] LI H M, WANG X C, ZHAO X F, et al. Understanding systemic risk induced by climate change[J]. Advances in Climate Change Research, 2021, 12(3): 384−394.

[26] KABRA R. Return of the inconsistent application of the “essential security interest” clause in investment treaty arbitration: CC/Devas v India and Deutsche Telekom v India[J]. ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, 2019, 34(3): 723−753.

[27] 杨秀, 李政. 减缓与适应并重 协同应对气候变化[N]. 光明日报, 2023−12−02 (09).

[28] JOHNSON L. International investment agreements and climate change: The potential for investor-state conflicts and possible strategies for minimizing it[J]. Environmental Law Reporter News & Analysis, 2009, 39(12): 11147−11160.

中国知网 https://www.cnki.net

[29] 冯存万. 浅析英国气候变化安全化及启示[J]. 复旦国际关系评论, 2021(2): 307−324.
[30] BREW R. Exception clauses in international investment agreements as a tool for appropriately balancing the right to regulate with investment protection[J]. Canterbury Law Review, 2019(25): 205−242.
[31] 刘冰玉. 气候治理投资安排: 溯源、沿革与新路径[J]. 法商研究, 2024, 41(4): 55−70.
[32] ROSEMBERG A, MAGRAW D, CHENNOUFI L, et al. Model green investment treaty: International investment and climate change[J]. Journal of International Arbitration, 2019, 36(1): 95−134.
[33] KALKHORAN M A, SABZEVARI H. Standards of review for the non-precluded measures clause in investment treaties: Different wording, different levels of scrutiny[J]. Netherlands International Law Review, 2021, 68(2): 281−314.
[34] RIFFEL C. The Chapeau: Stringent threshold or good faith requirement[J]. Legal Issues of Economic Integration, 2018, 45(2): 141−176.
[35] WANG W. The non-precluded measure type clause in international investment agreements: Significances, challenges, and reactions[J]. ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, 2017, 32(2): 447−456.
[36] 赵海乐. 一般国际法在“安全例外”条款适用中的作用探析[J]. 国际经济法学刊, 2021(2): 98−111.
[37] KURTZ J. Adjudging the exceptional at international investment law: Security, public order and financial crisis[J]. International and Comparative Law Quarterly, 2010, 59(2): 325−371.
[38] BURKE-WHITE W W, STADEN A V. Investment protection in extraordinary times: The interpretation and application of non-precluded measures provisions in bilateral investment treaties[J]. Virginia Journal of International Law, 2008, 48(2): 307−410.

The application of climate change measures under the security exceptions in international investment agreements: Feasibility and limitations

DENG Tingting, CAO Jiangqi

(School of Law, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: With the securitization of climate change, it is increasingly possible for host states to invoke the security exception clause of international investment agreements (IIAs) to defend their climate change measures in international investment arbitration cases. In recent years, the security exception clause in IIAs has shown a trend of expanding exceptions and lowering the nexus standard, both in the text of IIAs and in practice, which makes it feasible for host states to obtain exemptions from investment protection obligations for their climate change measures. Once the host states successfully cite the security exception clause, double effects will be evoked: it can, on the one hand, effectively safeguard the host states' right to regulate the climate, and may, on the other hand, further blur the thresholds and boundaries of the application of security exception clause, and increase the possibility of the clause being abused with the securitization of climate change. In order to safeguard the climate public interests of the host states while maintaining the contingent state of exception application and regulatory balance of the clause, countries should explicitly include climate change as a security exception, and rebalance the subjective and objective factors of the clause by incorporating the necessity standard of "least restrictive alternative measures" and increasing the limitations of its application. In interpreting and applying the security exception clause, arbitral tribunals should also make reasonable use of the evolutionary interpretation and refine the good faith standard of review, so as to limit the boundaries of the application of climate change measures to the clause.

Key words: climate change; international investment agreements; security exception clause; investment disputes related to climate change; securitization

[编辑：苏慧]

中国知网 https://www.cnki.net